



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZ. XIV CIVILE - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA "A"

Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:
dott. Claudio Marangoni presidente
dott. Caterina Macchi giudice rel.
Dott. Federico Rolfi giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite di I Grado, la prima iscritta al n. r.g. **29804/2015** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. NANNI ALBERTO, dell'avv. MIGLIACCIO MARCELLO e dell'avv. LANDI NICCOLO', elettivamente domiciliato MILANO presso il difensore avv. NANNI ALBERTO

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. GARGANO COSTANZA MARIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GARGANO COSTANZA MARIA

Pt_2 *Parte_3* (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. PINTO PASQUALE, elettivamente domiciliato presso il difensore

CP_2 C.F. *P.IVA_3*)

Controparte_3 C.F. *P.IVA_4*)

CP_4 C.F. *P.IVA_5*) tutte e tre le società con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO PASSAMANI, elettivamente domiciliate presso il difensore

CP_5 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. PERRON CABUS ANDREA e dell'avv. MARINI WALTER ROBERTO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PERRON CABUS ANDREA

La seconda iscritta al n. 477/2016 r.g. promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. NANNI ALBERTO, dell'avv. MIGLIACCIO MARCELLO e dell'avv. LANDI NICCOLO', elettivamente domiciliato MILANO presso il difensore avv. NANNI ALBERTO

ATTORE

contro

CP_6 (C.F. C.F._3), con il patrocinio dell'avv. PASSAMANI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore

CP_7 (C.F.), con il patrocinio dell'avv. SCORZA GUIDO e dell'avv. LASORSA BORGOMANERI NICCOLO' CP_8 e dell'avv. RECCIA DARIO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SCORZA GUIDO

CONVENUTI

Oggetto: concorrenza sleale e cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo,

All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti costituite così concludevano:

Per parte attrice:

CONCLUSIONI

piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, con riferimento ai due giudizi riuniti (R.G. n. 29804/2015 e n. 477/2016) così giudicare:

1.- dato atto, accertato e dichiarato che Controparte_1 ha svolto dal luglio 2013 una illecita attività di concorrenza sleale di sviamento delle campagne promozionali c.d. loyalty' CP_9 già ideate e/o programmate e/o organizzate e/o realizzate da Parte_1 nonché di storno dei dipendenti, dei consulenti e dei fornitori di Parte_1 nonché di sviamento a suo favore delle società licenziatricie dei marchi dei prodotti oggetto di dette campagne promozionali e dei clienti di Parte_1 rendendosi così responsabile di tali illeciti ex artt. 2598, n. 3, 2599, 2600, 2043 e 2055 cod. civ.; nonché

2.- dato atto, accertato e dichiarato che le condotte allegate e provate nel corso dei giudizi riuniti, poste in essere da ciascuno dei soggetti qui di seguito indicati, e cioè:

(i) il Signor CP_5 e la Signora CP_6 ,

(ii) il Signor Controparte_10 ,

(iii) le società Controparte_3 CP_4 e CP_2

(iv) la società Controparte_11 ,

costituiscono atti di illecita e sleale concorrenza eseguiti in concorso ed a sostegno della menzionata illecita attività di Controparte_1 nonché posti in essere in concorso tra di loro, in danno di Parte_1 rendendosi tali soggetti responsabili e corresponsabili con Controparte_1 dei danni subiti da [...] Pt_1 per i fatti ed i titoli di cui alla conclusione sub 1 e quindi ex artt. 2598, n. 3, 2599, 2600, 2043 e 2055 cod. civ.;

3.- per l'effetto degli accertamenti e delle declaratorie di cui ai punti 1 e 2 che precedono, condannare:

- Controparte_1

- il Signor CP_5 e la Signora CP_6 ,

- il Signor Controparte_10 ,

- le società Controparte_3 CP_4 e CP_2

- la società Controparte_11 ,

tutti in solido tra loro, a pagare ad Parte_1 a titolo di risarcimento dei danni da questa subiti per gli anni 2013, 2014 e 2015, sia in punto di danno emergente che di lucro cessante che di danno da perdita di chance, la somma di complessivi Euro 17.135.981,69, di cui Euro 1.591.876,65 quale danno emergente ed Euro 15.544.105,04 quale lucro cessante, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;

4.- emettere ogni altro provvedimento, declaratoria e statuizione del caso;

5.- in ogni caso con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori come per legge.

* * *

In via istruttoria:

6.- si chiede che, occorrendo, venga disposto un supplemento della CTU resa in data 27 novembre 2019 dal CTU designato, Dott. *Persona_1* al fine di determinare il Margine Operativo Lordo ("MOL") che *Parte_1* avrebbe conseguito negli esercizi 2013, 2014 e 2015 se avesse

Controparte_9 s programs oggetto di sviamento. E ciò, se necessario, attraverso il calcolo del MOL realizzato da *CP_1* per ciascuna delle menzionate operazioni, "normalizzando" tale MOL di Loyallteam e quindi determinandolo sulla base di una diligente e prudente organizzazione e gestione delle medesime operazioni di loyalty's programs secondo parametri di best practice. Relativamente alla quantificazione del danno subito da *Parte_1* per l'anno 2015, si chiede che, in ragione di quanto emerso in sede di CTU, lo stesso venga determinato, anche in via equitativa, tenendo conto del danno quantificato per il 2014, oppure mediante altro parametro;

7.- si ribadisce ed insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie svolte in corso di causa (per quanto non già ammesse dal Giudice Istruttore), qui da intendersi integralmente ritrascritte.

Per la parte convenuta *Controparte_1*

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

a) nel merito, respingere tutte le domande svolte da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* nonché la domanda di garanzia e manleva svolta in via riconvenzionale dal convenuto dott. *CP_10* nei confronti della stessa *Controparte_1* in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, sprovviste di prova;

b) in via istruttoria, la scrivente convenuta chiede di essere ammessa alla prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

1) vero che i documenti che mi si esibiscono (doc. 17, 18, 19) sono stati estratti dai siti internet di *Org_1*, *CP_12* e *Org_2* in data 08.02.2017;

2) vero che i dati contenuti nei documenti che mi si esibiscono (doc. 09-11 *CP_1*), ed in particolare quelli relativi ai costi, corrispondono ai costi sostenuti da *Controparte_1* rispettivamente nel corso degli esercizi 2013, 2014 e 2015;

3) vero che tra il 2013 ed il 2016 *CP_1* ha riacquisito dagli operatori della grande distribuzione organizzata beni rimasti invenduti al termine di campagne promozionali per un valore pari al 45 per cento dei propri ricavi;

4) vero che tra il 2013 ed il 2016 *CP_1* ha corrisposto ai titolari dei marchi apposti sui beni offerti in premio nell'ambito di campagne promozionali per la grande distribuzione organizzata royalty per oltre il 17 per cento dei propri ricavi

5) vero che *Parte_1* al termine dell'esercizio 2013 usciva dal mercato dei programmi fedeltà realizzati per la grande distribuzione organizzata;

6) vero che, nel settore dei programmi fedeltà realizzati per la grande distribuzione organizzata, è prassi che la realizzazione delle campagne venga affidata ad un'agenzia specializzata sulla base di una gara al miglior offerente;

7) vero che, nel settore dei programmi fedeltà realizzati per la grande distribuzione organizzata, è prassi che la realizzazione delle campagne, affidata come sopra ad agenzie specializzate, avvenga sulla base di specifiche direttive impartite dall'operatore della GDO, il quale precisa il tipo di prodotto da offrire in premio ai propri clienti.

8) vero che, nel settore dei programmi fedeltà realizzati per la grande distribuzione organizzata, è prassi che le agenzie specializzate di cui ai precedenti capitoli ordinino ed acquistino direttamente i

beni da offrire in premio ai clienti degli operatori della *Orga*, nonché stipulino direttamente contratti di licenza con i titolari dei marchi da apporre sugli stessi premi;

9) vero che, nel settore dei programmi fedeltà realizzati per la grande distribuzione organizzata, è prassi che l'agenzia specializzata rivenda all'operatore di *Orga* i premi acquistati dai rispettivi fornitori come al superiore capitolo;

10) vero che, nel settore dei programmi fedeltà realizzati per la grande distribuzione organizzata, è prassi che gli operatori della GDO impongano all'agenzia specializzata incaricata della realizzazione della campagna il riacquisto dei premi rimasti invenduti al termine dell'operazione;

11) vero che nel settore dei programmi fedeltà realizzati per la grande distribuzione organizzata, è prassi che i titolari dei marchi apposti su beni offerti in premio impongano la vendita degli stessi premi solo nell'ambito degli stessi programmi fedeltà per i quali sono stati realizzati.

12) Vero che *CP_1* ha realizzato tutte le proprie campagne promozionali aggiudicandosi le relative gare tra più agenzie indette dagli operatori della grande distribuzione organizzata, come è prassi nel settore dei programmi fedeltà.

13) Vero che, nel settore dei programmi fedeltà realizzati per la grande distribuzione organizzata, a partire dall'anno 2013 gli operatori della GDO hanno realizzato campagne promozionali di grandi dimensioni affidandone l'organizzazione alle agenzie specializzate di altrettanto grandi dimensioni.

Testimoni:

Su tutti i capitoli: *Testimone_1* residente a Milano, via Archimede 57;

Sui capitoli da 1) a 4), 12 e 13): *Testimone_2*, domiciliata a Padernello di Paese (TV), via Friuli 13;

Sui capitoli da 5) a 13): *Testimone_3* residente a Henonville (Francia), rue du Mesnil; [...] *Testimone_4*, residente a Cura Carpignano (PV), via San Epifanio 9; *Testimone_5* residente a Pozzuolo Martesana (MI) via Grosseto n. 20. *Testimone_6* residente a Milano, via Melchiorre Gioia 175.

Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, con i medesimi testi di cui sopra.

c) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario di legge.

Con salvezze illimitate.

Per la parte convenuta *CP_5*

Il sig. *CP_5*, rappresentato e difeso come in atti, chiede che questo Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, voglia:

In via pregiudiziale/preliminare:

dichiarare la propria incompetenza in relazione alle domande svolte da *Part* nei confronti del sig. *CP_5* stante la clausola arbitrale di cui all'art. 31 dello Statuto di tale società;

in subordine, dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità delle domande svolte da *Part* nei confronti del sig. *CP_5* per effetto della rinuncia all'azione pattuita nella transazione in data 2 dicembre 2013;

in ulteriore subordine, disporre lo stralcio dal fascicolo di parte attrice e, comunque, dichiarare l'inutilizzabilità ai fini della decisione della lite, in quanto costituenti corpo del reato e/o, in ogni caso, essendo cose pertinenti al reato, dei documenti prodotti da *Parte_1* sub docc. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 44, 45-bis, 47, 48, 65, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 105 (fasc. r.g. 29804/2015 ed r.g. 477/2016) 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 130 (fasc. r.g. 477/2016).

Nel merito:

rigettare tutte le domande svolte da *Part* nei confronti del sig. *CP_5* in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
con vittoria di spese e competenze della lite.

In via istruttoria:

si chiede ammettersi prova testimoniale e per interrogatorio formale del legale rappresentante di controparte sui seguenti capitoli di prova:

1. vero che il sig. *CP_5* ha iniziato la sua carriera professionale nella Grande Distribuzione Organizzata nell'anno 1992 presso il *Org_4* lavorando prima per *Org_5* e poi per *Org_6* ;
2. vero che nel 2003 il sig. *CP_5* aprì il primo *Organizzazione_7* in *Org_* insieme al sig. *CP_13*
3. vero che nel 2005 i sig.ri *Persona_2* e *Persona_3* affidarono al sig. *CP_5* [...] la Direzione Generale della società *Organizzazione_8* ;
10. vero che le campagne di loyalty program per la grande distribuzione organizzata vengono realizzate dalle agenzie selezionate come al precedente capitolo sulla base di specifiche direttive dettate dall'operatore della grande distribuzione;
11. vero che l'attività delle agenzie operanti nel settore dei loyalty program per la grande distribuzione organizzata consiste nell'ordinare ed acquistare i beni che verranno offerti in premio ai clienti degli operatori della grande distribuzione, i quali indicano preventivamente la tipologia merceologica degli stessi beni, nell'ambito delle rispettive campagne promozionali, nonché nello stringere accordi con le società titolari del marchio da apporre sui medesimi premi;
12. vero che, nel mercato dei loyalty program per la grande distribuzione organizzata, è costante prassi che i titolari del marchio apposto sui premi impongano che gli stessi premi possano essere utilizzati solo nell'ambito delle campagne promozionali per le quali sono realizzati, con esclusione della vendita diretta al pubblico;
21. vero che, quand'ero alle dipendenze di *Parte_1* svolgevo la mansione di impiegato commerciale addetto agli acquisti;
22. vero che, quand'ero alle dipendenze di *Parte_1* svolgevo la mansione di impiegato addetto all'amministrazione;
23. vero che ho redatto i documenti che mi si rammostrano, e che confermo i dati contenuti negli stessi (doc. 30 fasc. *CP_5*);
24. vero che i dati di bilancio di cui ai documenti che mi si rammostrano (doc. 30 fasc. *CP_5*) rappresentano la situazione contabile della società svizzera *Org_9* relativa agli anni 2014, 2015 e 2016.

Si indicano quali testimoni: sig. *Testimone_1* residente in Milano alla iva Archimede n. 57 (tutti i capitoli tranne 21-24); sig.ra *Testimone_3* residente in Henonville (Francia) alla rue du Mesnil (tutti i capitoli tranne 23-24); sig.ra *Testimone_4* , residente in Cura Carpignano (PV) alla via San Epifanio n. 9 (tutti i capitoli tranne 23-24); Sig. *Testimone_6* residente in Milano alla via Melchiorre Gioia n. 175 (tutti i capitoli tranne 23-24); sig.ra *Testimone_5* residente in Pozzuolo Martesana (MI) alla via Grosseto n. 20 (tutti i capitoli tranne 23-24); sig. *CP_13* presso *Organizzazione_10* corrente in 21000 Dijon (Francia) alla Rue Rousseau n. 109 (tutti i capitoli tranne 21-24); sig.ra *Testimone_7* presso *Org_11* corrente in 56900 Lugano alla Via Nassa n. 5 (capitoli tranne 23-24).

si chiede, inoltre, che la teste *Testimone_5* residente in Pozzuolo Martesana (MI) alla via Grosseto n. 20, in considerazione del fatto che - in virtù della sentenza di appello n. 504/2020 pubblicata dalla C.d.A. Milano, Sez. Lavoro, in data 8/9/2020 - è venuto in ogni caso meno il presunto e contestato motivo di presunta incapacità a testimoniare della stessa, ovvero la pendenza di una causa di lavoro connessa alla presente, si sentita a prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova già ammessi:

4. vero che dal 2007 al 2010 il sig. CP_5 ricoprì la funzione di General Manager Org_12 per Controparte_14 leader del settore dei loyalty program in Italia;

5. vero che il sig. CP_5 manifestava ai sig.ri Parte_4 e Parte_5 la propria intenzione di cessare tutti i propri rapporti professionali con Parte_1 sin dal maggio del 2013;

6. vero che il sig. Parte_4 era a conoscenza della costituzione della società Controparte_1 e del ruolo svolto in essa dal sig. CP_5 sin dal luglio del 2013;

7. vero che nell'ottobre del 2013 il sig. Parte_4 amministratore di Parte_1 manifestava l'intenzione di abbandonare il mercato dei loyalty program per la grande distribuzione organizzata, nonché di ridurre il personale di Parte_1 fino a due unità, come da documento che mi si rammostra (doc. 22 fasc. CP_5);

8. vero che Part abbandonava il mercato dei loyalty program per la grande distribuzione organizzata alla fine del 2013;

9. vero che le campagne di loyalty program per la grande distribuzione organizzata vengono di volta in volta singolarmente affidate dagli operatori della grande distribuzione ad un'agenzia specializzata, all'esito di una gara tra più agenzie;

13. vero che la campagna promozionale "coltelli Sabatier" realizzata da Part per CP_15 nel 2013 avrebbe dovuto avere una durata di tre mesi;

14. vero che CP_15 comunicò ai propri clienti la fine della campagna "coltelli Sabatier" realizzata da H2H a 10 giorni dall'inizio della medesima campagna, per l'esaurimento dei coltelli offerti in premio;

15. vero che la società cinese Organizzazione_13 produttrice dei coltelli ordinati da Parte_1 nell'ambito della campagna promozionale avente per oggetto i "coltelli Org_14", realizzata dalla stessa Parte_1 per CP_15, consegnò la maggior parte dei coltelli ordinati quando CP_15 aveva già dichiarato conclusa la medesima campagna promozionale;

16. vero che il ritardo nella consegna dei coltelli di cui al precedente capitolo fu conseguenza del ritardo con il quale Parte_1 aveva fornito ad Organizzazione_13 la lettera di credito pretesa da quest'ultima a garanzia del pagamento della fornitura di coltelli;

17. vero che i prodotti di cui alla fattura che mi si rammostra (doc. 53 fasc. H2H) sono stati rivenduti da CP_15 ad Parte_1 allo stesso prezzo unitario al quale Parte_1 li aveva in precedenza venduti a CP_15 ;

18. vero che Parte_1 si era contrattualmente obbligata nei confronti di CP_15 a riacquistare i prodotti di cui alla fattura che mi si rammostra (doc. 53 fasc. H2H);

19. vero che la società titolare del marchio Parte_6 imponeva contrattualmente ad Parte_1 di utilizzare i piatti e le tazzine sui quali veniva apposto il suddetto marchio esclusivamente nell'ambito di campagne promozionali realizzate per la grande distribuzione organizzata, con esclusione della vendita diretta al pubblico;

20. vero che la società titolare del marchio Parte_6 negava alla società francese Pt_7, che ne aveva fatto richiesta, la possibilità di vendere direttamente al pubblico i piatti e le tazzine contraddistinte dal marchio Parte_6 residuati al termine della campagna promozionale per i quali erano stati realizzati.

Ai fini di cui sopra, il convenuto Controparte_16 affinché questo Ill.mo Tribunale, premessa la pronuncia di ordinanza di rimessione in termini di cui all'art. 153 comma II c.p.c. e/o ogni diverso od ulteriore provvedimento necessario od opportuno, autorizzi la scrivente difesa al deposito del sopravvenuto dispositivo di sentenza n. 504/2020 della C.d.A. di Milano, sezione lavoro, pubblicata il 8.09.2020, che si allega, per esame, alla presente istanza sub doc. 36. Con riserva di formulare istanza per la produzione delle relative motivazioni, allorché depositate.

Si chiede, occorrendo, ammettere questa difesa alla prova contraria su tutti i capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi, con i seguenti testimoni: sig. Testimone_1 residente in Milano alla iva Archimede n. 57; sig.ra Testimone_3 residente in Henonville (Francia) alla rue du Mesnil;

sig.ra Testimone_4 , residente in Cura Carpignano (PV) alla via San Epifanio n. 9; Sig. Testimone_6 residente in Milano alla via Melchiorre Gioia n. 175; sig.ra Testimone_5 residente in Pozzuolo Martesana (MI) alla via Grosseto n. 20; sig. CP_13 presso Org_10 [...] corrente in 21000 Dijon (Francia) alla Rue Rousseau n. 109.
Salvis iuribus.

Per la convenuta CP_7 :

CP_7 , come sopra rappresentata e difesa, chiedendo che vengano assegnati alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, precisa le seguenti conclusioni:

Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni domanda diversa e contraria, così giudicare:

- in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano rispetto alle domande proposte da Parte_1 nei confronti della CP_7 per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
- nel merito, respingere integralmente le domande proposte da Parte_1 nei confronti della CP_7 [...] nel presente giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- sempre nel merito, ma in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la CP_7 fosse ritenuta responsabile dei fatti che le sono contestati a titolo di illecito ex artt. 2598 e/o 2043 c.c., dichiarare che Parte_1 non ha subito alcun danno ovvero, in via subordinata, limitare la condanna della CP_7 ai soli danni per cui risulti provata da parte di Parte_1 l'incidenza causale del fatto illecito ascritto alla CP_7 , graduando in ogni caso la responsabilità di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2055 c.c.;
- in via istruttoria, respingere la produzione documentale allegata da Parte_1 all'istanza del 22 luglio 2019 in quanto palesemente tardiva, poiché versata in atti ben oltre i termini di legge;
- sempre in via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ammettere, in riforma dell'ordinanza del 2 maggio 2017, la prova per testi sui capitoli di prova nn. 30-33, richiesta da [...] Pt_1 nella propria seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammettere CP_7 a prova contraria, così come articolata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.;
- in ogni caso, condannare Parte_1 per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della CP_7 di una somma pari al doppio delle spese di lite, da liquidarsi in funzione del valore che la società attrice ha attribuito alla presente controversia, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia su base equitativa;
- sempre, con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi incluse: (i) le spese della doppia fase cautelare svoltesi in corso di causa; (ii) le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della CP_7 [...] ; (iii) le spese sostenute dalla CP_7 per il proprio consulente tecnico di parte.

Si producono sub doc. 13 i giustificativi delle predette spese, come elencati nel documento riepilogativo allegato.

Per la parte convenuta Controparte_10 :

Voglia l'On.Tribunale adito così provvedere alla luce ragioni esposte in atti

- 1) Rigettare le domande proposte da Pt_1 nei suoi confronti con atto di citazione notificato il 5 maggio 2015 perché nulle, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi innanzi esposti;
- 2) In caso di mancata integrazione della domanda da parte di Pt_1 condannare quest'ultima al risarcimento del danno ex art. 96 cpc;
- 3) In caso di accoglimento integrale o parziale della domanda, condannare CP_1 a manlevare e garantire il dottor CP_10 da qualsiasi pronuncia a lui sfavorevole o pregiudizievole;
- 4) Vittoria nelle spese e competenze di causa.

Per la parte convenuta **CP_6** :

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie ritenute necessarie od opportune e rigettate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni dell'attrice, così provvedere e giudicare:

1. **Nel merito**, respingere le domande svolte da **Parte_1** nei confronti di **CP_6** , in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto nonché, in ogni caso, non provate.

In via di strettissimo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità della convenuta, graduare l'eventuale responsabilità della stessa in funzione del ruolo che all'esito del giudizio risulterà eventualmente ed effettivamente svolto dalla medesima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c.

2. **In via istruttoria**, a prova contraria rispetto a quanto dedotto e capitolato da parte attrice, si chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:

1) "Vero che, nell'intero corso degli anni 2013, 2014 e 2015, la sig.ra **CP_6** ha visitato gli uffici delle società appartenenti al **Org_15** siti in Milano alla via Panizza n. 7, con la frequenza di due volte alla settimana, com'è tutt'ora sua abitudine".

2) "Vero che, in occasione delle visite settimanali di cui al superiore capitolo, la sig.ra **CP_6** si è confrontata con il personale ed il management delle società del **Org_15** ovvero la stessa **Controparte_3** **CP_2** ed **CP_4** circa l'andamento dell'attività delle medesime compagini".

Si indicano quali testimoni: **Testimone_1** residente a Milano, via Archimede 57. **Testimone_2** , domiciliata a Padernello di Paese (TV), via Friuli 13.

Nella denegata ipotesi di ammissione di uno o più dei capitoli di prova formulati da parte attrice, la scrivente difesa chiede di essere ammessa alla prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, con i seguenti testimoni: **Testimone_1** residente a Milano, via Archimede 57. **Tes_2**

[...] , domiciliata a Padernello di Paese (TV), via Friuli 13. **Testimone_3** residente a Henonville (Francia), rue du Mesnil. **Testimone_4** , residente a Cura Carpignano (PV), via San Epifanio 9. **Testimone_5** residente a Pozzuolo Martesana (MI) via Grosseto n. 20.

Testimone_6 residente a Milano, via Melchiorre Gioia 175.

Con vittoria delle spese e delle competenze di lite.

Per le parti convenute **CP_3** , **CP_2** , **CP_4** :

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie ritenute necessarie od opportune e rigettate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni dell'attrice, così giudicare:

1. **in via pregiudiziale**, disporre lo stralcio dal fascicolo di parte attrice e, comunque, dichiarare l'inutilizzabilità dei documenti avversari sub **docc. nn. 34, 37, 39, 94, 95, 96, 97, 98, 124**;

2. **nel merito**, respingere le domande svolte da ^{Part} nei confronti di *Controparte_3* *CP_2* ed *CP_4* in quanto infondate e, in ogni caso, non provate.

In via di strettissimo subordine, graduare la loro eventuale responsabilità in funzione del ruolo effettivamente svolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c.

3. **in via istruttoria** si chiede ammettersi prova per testimoni sul seguente capitolo:

1) Vero che i bonifici bancari relativi al pagamento di Euro 363.000,00 in favore della società *Org_16* [...] e di Euro 60.500,00 in favore della società *Parte_8* di cui all'email del 31.07.2013 che mi si rammostra (doc. 39 fasc. H2H), sono stati disposti dalla società *Controparte_3* Si indica quale testimone: *Testimone_2*, presso *CP_4* corrente in Paese (TV), Frazione Padernello, Via Friuli 13.

Nella denegata ipotesi di ammissione di uno o più dei capitoli di prova formulati da parte attrice, la scrivente difesa chiede di essere ammessa alla **prova contraria** sui capitoli avversari eventualmente ammessi, con i seguenti testimoni: *Testimone_1* residente a Milano, via Archimede 57. *Tes_2*

[...], domiciliata a Padernello di Paese (TV), via Friuli 13. *Testimone_3* residente a Henonville (Francia), rue du Mesnil. *Testimone_4*, residente a Cura Carpignano (PV), via San Epifanio

9. *Testimone_5* residente a Pozzuolo Martesana (MI) via Grosseto n. 20.

Testimone_6 residente a Milano, via Melchiorre Gioia 175.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Motivi della decisione

La presente sentenza conclude il giudizio di primo grado di due cause riunite, entrambe instaurate da *Parte_1*. Si rappresentano qui, sinteticamente, le domande sulle quali il Tribunale si deve pronunciare, senza menzione di quelle rinunciate nella fase di esordio del contenzioso.

Part è società che operava dal 2011 nel settore delle operazioni di fidelizzazione della clientela a favore delle reti di vendita appartenenti alla Grande Distribuzione Organizzata, ed aveva acquisito importanti clienti nella *Orga* in *CP_15* (*Org_17* *Parte_7* , *Org_18*), con prospettive di crescita sul mercato europeo e fatturato in significativo incremento. L'attrice ha dedotto di aver subito tra la metà del 2013 e la metà del 2014 condotte di concorrenza sleale che le hanno fatto perdere irreversibilmente dipendenti, clientela e redditività aziendale a favore di *Controparte_1* con il concorso di molti altri soggetti: segnatamente, *CP_5* , *Controparte_10* , *CP_4* , *Controparte_3* , *Controparte_17* , convenuti insieme a *CP_1* nella prima causa; e di *CP_6* e *CP_7* convenute nella seconda causa. Tali soggetti sono stati convenuti quali terzi interposti nella concorrenza sleale perpetrata da *CP_1* , con attribuzione a ciascuno di condotte inscritte in un quadro di convergente interesse alla programmazione e realizzazione di un piano illecito che ha sostanzialmente sottratto a *Part* la sua azienda; di *CP_6* è stata anche dedotta la qualità di amministratore di fatto di *CP_1* nel periodo che precede la sua assunzione della qualità di amministratore di diritto della società; anche di *CP_10* è stata prospettata una responsabilità quale amministratore di *CP_1* .

L'attrice ha chiesto l'accertamento dell'illecito e la condanna in solido delle parti convenute al risarcimento dei danni sofferti, quantificati in € 17.135.981,69, di cui € 1.591.876,65 a titolo di danno emergente e € 15.544.105,04 a titolo di lucro cessante. Le conclusioni sono le stesse in entrambi gli atti di citazione.

Tutti i convenuti si sono regolarmente costituiti in giudizio, contestando integralmente le domande dell'attrice e chiedendone il rigetto. Le rispettive prospettazioni ed eccezioni verranno illustrate nello sviluppo della motivazione.

Il giudice istruttore investito della seconda causa ha ordinato ex art. 164 comma IV c.p.c. l'integrazione dell'atto di citazione, cui H2H ha regolarmente provveduto. All'udienza del 25 ottobre 2016 è stata disposta la riunione dei due giudizi. Sono quindi stati assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; è seguita una ampia istruttoria orale, e l'espletamento di una complessa consulenza tecnica contabile.

Precisate le conclusioni come riportate in epigrafe, depositate le memorie finali, su richiesta della parte attrice si è svolta discussione orale avanti al collegio ex art. 275 c.p.c.; all'esito le due cause riunite sono state trattenute in decisione.

Il tribunale accoglie le istanze ex art. 153 II comma c.p.c. formulate dalla difesa di ^{Part} sia nella comparsa conclusionale, sia con istanza in data 18 febbraio 2021 e ammette la produzione dei seguenti documenti: consulenza informatica resa dal dott. Giuseppe Tosini nel proc. Pen. N. 27180/15 r.g. notizie di reato; richiesta di archiviazione formulata dal PM nel medesimo procedimento; sentenza 8115/2020 r.g. del Tribunale di Milano sez. V civile; istanza di rilascio di copia del decreto di archiviazione nel predetto procedimento penale n. 27180/2015 r.g.; decreto di archiviazione medesimo, allegato alla nota di deposito del 2 marzo 2021: si tratta in ciascun caso di documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie.

Detta condizione non ricorre invece con riferimento ai documenti oggetto di analoga istanza depositata in data 22 luglio 2019, trattandosi di documenti risalenti al 2013 (costituiti da verbale del cda di ^{Part} 11.7.2013, verbale cda ^{Org_19} 28.3.2013 e bilancio ^{Org_19} 2013) per i quali non è provata alcuna ragione ostativa ad una tempestiva produzione in giudizio.

A fronte della notevole articolazione dei fatti dedotti in causa, ragioni di chiarezza consigliano di focalizzare quello che deve essere considerato il nucleo essenziale delle condotte concorrenzialmente sleali allegate dalla parte attrice, vale a dire i fatti ascritti a ^{CP_5} e a ^{CP_1} ; correlativamente, verranno subito prese in considerazione le contestazioni formulate dai predetti due convenuti.

Sono da esaminarsi innanzi tutto le eccezioni preliminari di ^{CP_5} .

Il predetto convenuto ha infatti svolto eccezione di compromesso con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 31 dello statuto di H2H, a mente della quale "Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della camera Arbitrale nazionale e Internazionale di Milano (...) Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale". L'eccezione è da rigettarsi, apparendo palese che la presente controversia non ha ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, essendo stata esercitata azione extracontrattuale volta a far accertare la responsabilità del ^{CP_5} quale autore di condotte illecite e concorrente nell'illecito concorrenziale ex art. 2598 n. 3 c.c. di ^{CP_1} .

CP_5 ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'azione nei suoi confronti per effetto della scrittura transattiva sottoscritta tra il medesimo convenuto e **Part** in data 2 dicembre 2013, avuto riguardo alla portata omnicomprensiva del negozio transattivo, mediante il quale le parti hanno risolto consensualmente tutti i rapporti tra loro intercorsi dichiarando di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra. L'eccezione è palesemente infondata, atteso che all'epoca della sottoscrizione della transazione **Part** non era a conoscenza delle condotte del **CP_5** che l'attrice ha poi posto a fondamento delle domande risarcitorie qui azionate: la volontà conciliativa delle parti, come emerge dalla lettura del testo, è evidentemente riferita solo alle vicende già note, e non anche a qualsiasi pretesa o ragione fondata su fatti non conosciuti.

Come già ricordato, **Part** deduce la messa in atto ai suoi danni di orchestrate condotte illecite che hanno determinato lo sviamento dell'intera sua azienda, collocate tra la metà del 2013 e la metà del 2014.

Part (la cui denominazione originaria era **Organizzazione_20** è stata iscritta al registro delle imprese il 1° dicembre 2010, con socio unico **Controparte_18** A latere della costituzione della società è stato stipulato un accordo tra **CP_18** **CP_5** e **Parte_4** in forza del quale è stato previsto che al raggiungimento di determinate soglie di fatturato da parte di **Part** gli stessi ne sarebbero divenuti soci con una partecipazione al capitale del 24.5% ciascuno. Cosa che avvenne pressoché immediatamente, come documentato dal patto parasociale del 24 gennaio 2012 documentato dallo stesso **CP_5** (suo doc. 5)

Part è stata inizialmente amministrata da **Controparte_10** quale a.u., e dal 22 giugno 2012 da un cda composto da 5 membri, tra i quali **CP_5** quale consigliere delegato dal 22 giugno 2012 al 2 dicembre 2013. **CP_5** era anche dipendente di H2H dal 25 luglio 2012.

La struttura organizzativa aziendale era costituita da un ristretto numero di dipendenti (6 in tutto, compreso il **CP_5**) e da alcuni consulenti (**Organizzazione_10** **Persona_4** **Persona_5** **Persona_6**) che svolgevano un importante ruolo di assistenza nell'ideazione, allestimento e attuazione delle singole operazioni contrattuali.

L'illustrazione delle circostanze rilevanti richiede un preliminare richiamo alle caratteristiche intrinseche dell'attività svolta. H2H operava quale agenzia di programmi di fidelizzazione: l'attività consiste nella ideazione di un programma di fidelizzazione (loyalty program) per una società della **Orga**. Ciò richiede: l'individuazione da parte dell'agenzia un marchio che possa essere attraente per la clientela dell'operatore della grande distribuzione (che è il cliente di **Part**), e quindi di un prodotto con

uno specifico design da associare al brand selezionato; la creazione di una specifica campagna pubblicitaria e di presentazione della proposta ai consumatori, clienti della società della *Orga*. E' da notare ulteriormente che in tal genere di operazioni incombe sull'agenzia la stima della quantità di prodotti necessari per attuare la singola campagna promozionale e la conseguente valutazione del rischio dei resi: rischio che resta a carico dell'agenzia stessa, e non trasla a carico della società della *Orga* con la quale il contratto viene stipulato. L'attrice ha documentato la propria collocazione sul mercato della *Orga* francese e belga grazie a programmi di fidelizzazione realizzati con successo fino alla prima metà del 2013.

In data 22 luglio 2013 è stata costituita *CP_1* da parte di *CP_10* *Controparte_19* e *Controparte_20*. È acclarato in giudizio e assolutamente pacifico che le due fiduciarie schermassero la partecipazione al capitale di rispettivamente di *CP_5* e di *Controparte_3*. A quella data *CP_5* era consigliere delegato, socio e dipendente di *Part*. E' documentato e incontestato che tutti i dipendenti di *Part* si sono dimessi tra luglio e dicembre 2013: *Testimone_5* il 29.7.2013, *Testimone_4* il 30.8.2013, *Testimone_6* il 15 .11.2013, *Org_21* il 15.12.2013 e sono stati assunti contestualmente da *CP_1*; alcuni di essi (*Tes_5* e *Tes_6* doc. 16 e 18 attore) si sono dimessi senza prestare il periodo di preavviso. *CP_5* ha lasciato H2H il 2 dicembre 2013. L'unico soggetto facente parte della compagine di H2H non fuoriuscito è *Parte_4* *CP_1* ha il medesimo oggetto sociale di *Part* e ha immediatamente avviato la sua operatività nel medesimo settore, con rilevante e immediato successo, attestato da un volume di affari di quasi 5 milioni di euro nello stesso anno 2013 e di oltre 47 milioni nel 2014. Anche tutti i consulenti di H2H, incontestatamente, hanno avviato collaborazioni con *CP_1*. *Part* ha inoltre subito un integrale sviamento della sua clientela, operata tramite il trasferimento a *CP_1* delle campagne promozionali ideate da *Part*, che sono state realizzate da *CP_1*.

Va ora considerata l'eccezione di inammissibilità/inutilizzabilità di una parte del materiale documentale prodotto da *Part*, sollevata dalle difese di *CP_5*, *CP_1*, *CP_6* *CP_3* +2, con riferimento al contenuto di numerose mail che sono state cercate dall'attrice sui pc aziendali in uso a taluni ex dipendenti di *Part* (in particolare *Testimone_5* è incontestato che *CP_5* non abbia mai restituito il pc aziendale) e sul backup delle caselle di posta elettronica aziendale estratti dal server aziendale di *Part* da parte di un tecnico specializzato, dott. *Per_7*.

L'inammissibilità di tali prove, o comunque la loro inutilizzabilità, è stata dedotta sottolineando in particolare che la condotta di acquisizione delle mail messa in atto da *Part* integra la fattispecie dei

reati di cui agli artt. 615 ter e 616 c.p. A tale riguardo infatti, sia CP_5 sia le società CP_3 CP_4 e CP_2 hanno depositato denuncia querela.

Ciò che tuttavia risulta decisamente rilevante è la non contestazione dei fatti allegati dalla parte attrice. Part nei suoi atti introduttivi (i due atti di citazione e l'integrazione depositata ex art. 164 IV c.p.c.) ha infatti allegato l'indicazione di una serie di loyalty program predisposti dalla stessa attrice e tutti realizzati da CP_1 , ed ha enunciato ed illustrato diffusamente quali fatti costitutivi dell'illecito una serie di circostanze del tutto specifiche e temporalmente individuate, che consistono in contatti via mail a partire da luglio 2013 tra CP_5 e altri dipendenti di Part (progressivamente nel tempo ex dipendenti) ovvero consulenti di Part , e tra questi e la clientela ovvero i fornitori di Part ; contatti nei quali, ad esempio, sia a clienti sia a fornitori di Part viene comunicato che la fatturazione sarà da fare a un nuovo soggetto, vale a dire CP_1 ; o addirittura che Part dopo l'estate del 2013 avrebbe mutato denominazione in CP_1 . Ora, nessuna delle parti a ciò titolate contesta tali specifici fatti nella loro consistenza materiale – e ciò è particolarmente significativo quanto al convenuto CP_5 - bensì ciascuna offre letture diverse da quella attorea della complessiva caratterizzazione della vicenda snodatasi tra il 2013 e il 2014. Il quadro fattuale allegato dalla parte attrice sin dai suoi atti introduttivi quanto agli scambi di informazioni tra dipendenti, consulenti, fornitori, clienti, come anche con alcuni degli odierni convenuti o loro dipendenti/rappresentanti risulta dunque confermato ex art. 115 c.p.c. dalla mancata contestazione avversaria, tanto più significativa in quanto si tratta non di un mero silenzio su tali fatti, ma della prospettazione di un diverso significato giuridico della complessiva vicenda entro cui essi si inscrivono.

Ciò chiarito si svolgono in ogni caso alcune considerazioni sul tema della dedotta inammissibilità delle prove documentali in discussione, per rilevare l'infondatezza della prospettazione dei convenuti. Richiamando un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, il Collegio rammenta in primo luogo che il codice di procedura civile non contiene alcuna norma che sancisca un principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite in violazione di legge; inoltre, l'art 160 n 6 d.lgs. 196/2003 stabilisce che la validità e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di documenti, basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge, restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali della materia penale e civile. Il contemperamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di difesa è quindi rimesso, in assenza di una precisa norma processuale civile, alla valutazione del singolo giudice nel caso concreto (cfr. Cass. 7466/2013; 18279/2010; Cass. S.U. 3034/2011; Trib. Milano ord. 17.12.2015 est. Marangoni; Trib. Milano sent. 9431/16; Trib. Milano 9109/2015 est. Tavassi; Trib. Torino, 8 maggio 2013).

La parte attrice ha ampiamente illustrato e documentato in giudizio le modalità attraverso le quali tali documenti siano stati acquisiti. Viene in primo luogo in considerazione al riguardo la perizia tecnica depositata quale doc. 164, che illustra precisamente sia la provenienza dei dati estratti, sia le modalità di analisi ed estrazione. Ma vengono in considerazione altresì tre documenti prodotti nella fase finale del processo, ammessi ex art. 153 II c.p.c. in esordio della presente motivazione. Si tratta della perizia tecnica disposta dal Pubblico Ministero nel contesto del procedimento penale n. 27180/2015 apertosi su denuncia (tra gli altri e per quanto qui interessa) di CP_2 e di CP_4 in relazione ai delitti di cui agli art. 615 ter c.p. e 616 c.p.; della richiesta di archiviazione formulata dal PM in esito agli accertamenti svolti; del decreto di archiviazione pronunciato dal GIP in data 20.10.2020 (doc. A,B,M attore). Emerge con precisa convergenza di risultati di indagine che gli elementi documentali di cui si discute sono stati reperiti sui server aziendali in una cartella di default di Microsoft Outlook, accessibile senza password private del dipendente; e che nessun accesso a indirizzi privati è stato compiuto da parte del tecnico officiato da Part , sì che l'estrazione delle mail rese poi oggetto di produzione in giudizio non configura alcuna violazione di norme penali. Si riporta in calce una parte della motivazione del decreto di archiviazione pronunciato dal GIP:

In particolare, dalla relazione tecnica del consulente nominato dal PM, si ricava che una copia di tale corrispondenza era stata rinvenuta nel pc aziendale in uso a Corinne Guiral, all'interno di una cartella di default di Microsoft Outlook, originata mediante un meccanismo di copia e salvataggio automatico della stessa.

Invero, l'account di Corinne Guiral era stato, in precedenza, sincronizzato con il pc aziendale mediante Outlook, in modo tale da gestire le comunicazioni senza accedere al web; in tal modo, una volta effettuato l'accesso tramite Outlook, copia dei messaggi era scaricata e salvata in locale.

Ciò detto, a ben vedere, non vi è stata, da un lato, alcuna violazione in senso proprio della corrispondenza citata, in quanto corrispondenza che non può definirsi "chiusa"; né può dirsi, dall'altro lato, che vi sia stato un accesso abusivo ad un sistema informatico, in quanto H2H Srl non effettuava alcun accesso all'indirizzo di posta elettronica appartenuto in precedenza a Corinne Guiral, ma ne rinveniva copia in una cartella non protetta da alcuna password o altro sistema di sicurezza, liberamente accessibile dall'azienda.

Sul punto, la Suprema Corte ha recentemente affermato, con riferimento ad un sistema informatico utilizzato da una Pubblica Amministrazione, che è configurabile il reato di cui all'art. 615 ter c.p. anche qualora l'accesso venga effettuato su un account mail aziendale protetto da password, in quanto le caselle mail rappresentano il domicilio informatico del dipendente. In particolare, la presenza di una password *"dimostra che a quella casella è collegato uno ius excludendi di cui i superiori devono tener conto"* (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 13057/2016).

Nel caso di specie, però, non vi è stato alcun accesso abusivo, né violazione di corrispondenza, proprio perché il contenuto della stessa era liberamente accessibile; non si può, infatti, affermare che la sincronizzazione dell'account email con il pc aziendale non fosse circostanza conosciuta da Corinne Guiral, non emergendo evidenze contrarie in tal senso, ma solo mere illazioni da parte degli oppositori.

E' da sottolineare inoltre che il procedimento seguito dal tecnico officiato da ^{Part}, dr. ^{Per_8} [...] per estrarre i dati è pienamente conforme alle regole dell'informatica forense, ciò essendo stato confermato dal CT del PM, dott. Tosini; detta conformità non è peraltro mai stata dubitata in causa. E va nuovamente ricordato che nemmeno è stato mai contestato in causa che i documenti che ^{Part} ha tratto dal server aziendale fossero genuini: in altre parole, né la provenienza delle mail o l'avvenuta ricezione è disconosciuta da alcuno dei soggetti che a ciò fossero legittimati, né il contenuto delle singole mail è investito di alcuna contestazione di non veridicità. L'unico profilo contestato attiene, come detto, alla illiceità dell'acquisizione delle prove, illiceità che non ricorre, essendo smentita dagli elementi sopra richiamati. I documenti prodotti sub 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 44, 45-bis, 47, 48, 65, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 105 (fasc. r.g. 29804/2015 ed r.g. 477/2016) 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 130 sono dunque pienamente ammissibili.

Emerge con evidenza che all'integrale trasferimento della struttura operativa di ^{Part} in CP_1 si sia accompagnata la perdita a favore di CP_1 di tutte le campagne di fidelizzazione ideate e/o realizzate. Si tratta delle seguenti operazioni: Org_22 Eclipsis, presentata da ^{Part} a CP_15 nell'aprile 2013 e realizzata da CP_1 non solo per CP_15 ma successivamente anche per altri operatori della GDO; coltelli Org_14 realizzata da H2H nella prima metà del 2013 per [...] CP_15, e riproposta da CP_1 per il gruppo Org_4 nel 2014; Parte_6 realizzata da H2H per Parte_7 tra marzo e giugno 2013, e riproposta da CP_1 per CP_7 Belgio a maggio 2014; CP_21 approvata dal cliente Org_4 ad agosto del 2013 e realizzata da CP_1 per varie società del gruppo Org_4 nel 2014; Org_23 progettata da ^{Part} per Org_4 e confermata dal cliente nell'agosto 2013, ma poi realizzata da CP_1; Spongebob, realizzata da ^{Part} per CP_15 tra agosto e novembre 2013, e proposta da CP_1 tra marzo e maggio 2014 per CP_22 secondo le medesime caratteristiche di configurazione della campagna e dei prodotti, con la sola variazione del tema (Puffi e non Spongebob); operazione sticker/realità aumentata, consistente nella realizzazione di sticker/card abbinate a giochi per cellulari, sviluppata da H2H per CP_15 sino alla fase della realizzazione di una demo del software, e poi realizzata da CP_1 per Org_4 utilizzando card raffiguranti i giocatori della nazionale francese in corrispondenza della Organizzazione_24.

Tale esito è stato ottenuto dal CP_5 insieme con i dipendenti stornati di ^{Part} e i consulenti della stessa. Si rinvia a quanto sopra già osservato con riferimento alla non contestazione dei fatti relativi alla fitta serie di comunicazioni di CP_5, dipendenti e consulenti stornati, verso clienti e fornitori di ^{Part}. Si richiama inoltre quanto è stato già riscontrato da questo Tribunale nell'ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. di accoglimento della richiesta di sequestro conservativo in corso di causa formulata da ^{Part} verso CP_5, dove il Collegio ha sottolineato come non fosse contestato, oltre che validamente documentato, che *la gran parte dei clienti di CP_1 coincidesse con quelli di ^{Part} e che CP_1 abbia realizzato alcune campagne promozionali che ^{Part} aveva ideato e in taluni casi già in parte attuato. E' documentato che, nell'imminenza della costituzione della nuova società CP_1, il sig. CP_5, quando ancora rivestiva la carica sociale presso la ricorrente, trattando con i clienti della prima, ingenerasse l'equivoco che la – costituenda- società CP_1 fosse la medesima società ricorrente, che cambiava solo denominazione, così sfruttandone l'avviamento e l'accreditamento. In proposito, si riporta l'eloquente corrispondenza intervenuta nell'agosto 2013 tra il sig CP_5 e il cliente Org_4 "IMPORTANT: Vi comunico che il nostro Gruppo è stato riorganizzato durante l'estate e ha modificato la struttura societaria e il nome della nostra organizzazione che ora si chiama CP_1 e non più H2H. A seguito di questa riorganizzazione, saremo lieti di conoscervi personalmente, vi preghiamo di contattare CP_23 e me esclusivamente sul nostro nuovo recapito*

email (Email_1 e Email_2 a causa dell'impossibilità di leggere le vostre comunicazioni sugli indirizzi precedenti. CP_24 ” (cfr doc 78 ric.)”.

Sono da respingere tutte le eccezioni svolte dalle parti convenute, che contestano il ricorrere degli elementi costitutivi della concorrenza sleale.

È in primo luogo radicalmente infondata ogni asserzione circa l'insussistenza di un rapporto di concorrenzialità tra Part e CP_1 . Pacifico che entrambe si rivolgessero alla stessa clientela, visto che l'oggetto sociale era il medesimo e che l'attività in concreto svolta era esattamente la stessa, l'eccezione ruota intorno all'asserita mancanza di compresenza temporale delle due imprese sul medesimo mercato, perché prima di luglio 2013 CP_1 ancora non esisteva, e nell'autunno del 2013 H2H aveva deciso di lasciare il mercato dei programmi di fidelizzazione. Si prendono le mosse dal più che consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di concorrenza potenziale tra imprese, secondo cui “In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile della fattispecie di illecito prevista dall'art. 2598 cod. civ. è la sussistenza di una effettiva situazione concorrenziale tra soggetti economici, il cui obiettivo consiste nella conquista di una maggiore clientela a danno del concorrente. Ne consegue che la comunanza di clientela - data non già dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti delle due imprese, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato, e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare - è elemento costitutivo di detta fattispecie, la cui assenza impedisce ogni concorrenza, non potendo ritenersi decisiva di per sé, a tali effetti, la circostanza, da utilizzare solo come criterio integrativo, della identità del procedimento di commercializzazione adottato. Peraltro, la sussistenza della predetta comunanza di clientela va verificato anche in una prospettiva potenziale, dovendosi, al riguardo, esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e, quindi, su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini o succedanei rispetto a quelli attualmente offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale” (Cass. 1617/2000).

Orbene, nel caso di specie si è al cospetto di un fenomeno ben più nitido nei suoi contorni di quello della concorrenza potenziale tratteggiato dalla sopra citata giurisprudenza, riferita alla naturale dinamicità dell'attività di un'impresa già esistente: CP_25 è infatti stata costituita allo scopo di operare esclusivamente nel mercato in cui operava H2H e dunque con un intendimento certo, e non affatto potenziale, di porsi in concorrenza con l'odierna attrice. L'attività preparatoria, come esattamente ricordato dalla parte attrice, non sfugge affatto agli obblighi di correttezza e va valutata alla

stregua dei principi sanciti dall'art. 2598 c.c., come già affermato da questo Tribunale : *“Può essere soggetto attivo e passivo di condotte anticoncorrenziali anche il soggetto che sta procedendo alla predisposizione di un'organizzazione d'impresa, in vista di un non ancora realizzato ingresso nel mercato, laddove l'iniziativa imprenditoriale non si trovi in fase meramente progettuale o preparatoria, ma sia in atto un procedimento organizzativo già obbiettivamente estrinsecatosi”*(cfr. Trib. Milano, Ord. 18 agosto 2005).

Il tema, poi, della asserita volontà di ^{Part} di lasciare per il futuro il mercato dei loyalty program, oggetto anch'esso di profuse difese, è inconferente rispetto alla individuazione delle condotte illecite e la sua rilevanza al riguardo è da escludere con decisione. Esso è invocato come una sorta di scriminante delle condotte di CP_5 e CP_1 , al fine di avvalorare l'irricevibile tesi di una sorta di diritto ad appropriarsi dell'intera organizzazione aziendale e della clientela altrui come se potessero configurarsi condizioni legittimanti la radicale destrutturazione di un'impresa concorrente, presente sul mercato e con operazioni contrattuali progettate, quale H2H era certamente mentre subiva le condotte illecite. La tesi sostenuta in vario modo dalle difese dei convenuti e in particolare da quella di CP_5 , che sembra giustificare la distrazione dell'azienda altrui, non sembra richiedere ulteriori considerazioni.

Non dissimili conclusioni si devono raggiungere con riguardo alle ulteriori contestazioni, attinenti alla insussistenza dello storno dei dipendenti, alla inconfigurabilità intrinseca di uno storno di consulenti, come anche di un portafoglio clienti che un operatore possa vantare nel settore di cui si discute. Un tratto comune di queste eccezioni è quello di tentare di proporre una lettura atomistica degli elementi che costituiscono la fattispecie: ma tale lettura tradisce la realtà dei fatti, i quali per la loro contestualità cronologica ed evidente funzionalità ad un unico e inequivoco fine, debbono essere unitariamente considerati.

Quanto allo storno dei dipendenti: si è al cospetto, come già più volte detto, di una integrale scomparsa della struttura organizzativa di ^{Part} , che ricompare presso CP_1 . Tale è la pregnanza del fenomeno da rendere autoevidente come esso non possa essere riduttivamente letto in termini di un libero esercizio di autonomia negoziale dei soggetti coinvolti (come sembra fare CP_1 , che enfatizza la regolarità delle dimissioni e la regolarità delle successive assunzioni dei dipendenti). Ed infatti, certamente ricorrono nel caso di specie sia le modalità non fisiologiche del trasferimento del personale, in quanto palesemente tali da mettere a rischio la continuità aziendale dell'imprenditore che subisce lo storno nella sua capacità competitiva; sia la non prevedibilità delle modalità dell'evento, certamente in grado di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili, e tale da determinare un effetto di *shock* sull'ordinaria attività di offerta di beni o di servizi dell'impresa che subisce lo

storno; sia la violazione della disciplina giuslavoristica, atteso che alcuni dipendenti hanno rifiutato di lavorare il preavviso. Quanto ai consulenti, è pacifico che nell'organizzazione aziendale molto leggera di ^{Part} essi svolgessero un ruolo fondamentale di assistenza specifica alla predisposizione delle singole campagne e al rapporto con il singolo cliente, e che abbiano proseguito a svolgere per ^{CP_1} identiche prestazioni sulle operazioni contrattuali che ^{Part} aveva avviato/realizzato, fino a coinvolgersi direttamente (come nel caso di ^{CP_13} nella diffusione di informazioni false su una inesistente identità tra ^{Part} e ^{CP_1} : anche tali condotte concorrono dunque a delineare le caratteristiche e le dimensioni dell'illecito.

Quanto alla clientela, ancora una volta si rivelano fallaci le impostazioni difensive che enfatizzano l'insussistenza di una clientela fidelizzata in un mercato di operazioni particolari e complesse come quello in questione, in cui gli operatori della GDO generalmente mettono in gara una pluralità di offerenti. Nel caso di specie, quello che è accaduto è che nei fatti tutte le operazioni contrattuali degli anni 2013 e 2014 di ^{CP_1} sono operazioni che erano state ideate e in parte attuate da ^{Part}, ed è evidente che ciò è accaduto attraverso l'appropriazione di tutto l'apparato organizzativo e del know how aziendale, con financo l'utilizzo di false informazioni alla clientela – come si è visto – quanto ad una asserita identità/continuità tra ^{Part} e ^{CP_1} .

Vi è un ulteriore tema che ha occupato significativamente il tempo del processo e le difese, ed è quello che attiene alla capacità finanziaria di ^{Part} ; detto profilo tuttavia non incide affatto sulla fisionomia delle condotte illecite, tantomeno elidendola, bensì trova la sua esatta collocazione nella quantificazione del danno sofferto dall'attrice e verrà affrontato in tale sede.

La realtà dei fatti attesta, dunque, la fondatezza della domanda attorea quanto alle condotte di concorrenza sleale, che sono da ascrivere a ^{CP_1} con il concorso di ^{CP_5} . Sono ampiamente comprovate le condotte illecite di quest'ultimo, ideatore ed attuatore dello storno dei dipendenti, dei consulenti, del know how aziendale e della clientela, ed è palese la relazione di interessi tra lo stesso ^{CP_5} e ^{CP_1} . A tale specifico riguardo si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità, altrettanto condivisa dai giudici di merito, che trova in Cass. 18772/19 la seguente persuasiva enunciazione, che ripercorre i più significativi precedenti della stessa Corte di legittimità: *“Il principio secondo il quale la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato della concorrenza, non configurabile, quindi, qualora non sussista il cosiddetto «rapporto di concorrenzialità», non esclude la sussistenza di un atto di concorrenza sleale anche nel caso in cui tale atto sia posto in essere da colui il quale si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, in grado di far ritenere che l'attività sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di*

quest'ultimo; peraltro, a tal fine, è insufficiente la mera circostanza del vantaggio arrecato all'imprenditore ricorrente, ma neppure occorre che sia stato stipulato con questi un *paCTUm sceleris*; è infatti sufficiente il dato oggettivo consistente nella esistenza di una relazione di interessi tra autore dell'atto ed imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l'attività del primo può integrare semmai un illecito ex art. 2043 cod.civ. ma non un atto di concorrenza sleale (Sez.1, 08/09/2003, n. 13071). A tale riguardo la giurisprudenza di questa Corte ravvisa il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori nel contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune e precisa che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno (Sez. 1, 18/05/2018, n. 12364). Analoghi comportamenti posti in essere da un soggetto non imprenditore potranno semmai assumere rilievo alla luce delle regole generali che disciplinano l'illecito aquiliano ex art.2043 cod.civ. Tuttavia la giurisprudenza di questa Corte ha ammesso l'ipotesi in cui gli illeciti anticoncorrenziali siano compiuti da un terzo c.d. «interposto», il quale agisca per conto, o comunque in collegamento con un imprenditore che ne trae vantaggio, concorrente di quello danneggiato, concludendone che entrambi rispondono in via solidale a titolo di concorrenza sleale (Sez.1, 23/12/2015, n. 25921). Lo schema concettuale che viene trasposto in subiecta materia è analogo a quello, tipicamente penalistico, del concorso di persone nel «reato proprio», che presuppone quindi il possesso di una certa qualità soggettiva da parte dell'agente, alla cui azione può partecipare anche il cosiddetto *extraneus*, rispondendo anch'egli del reato. Si è detto peraltro che ai fini della configurabilità della fattispecie di concorrenza sleale per interposta persona ex art. 2598 cod.civ., non si richiede un vero e proprio *paCTUm sceleris* tra l'imprenditore concorrente e il terzo, ma è necessaria (e sufficiente) una relazione di interessi tra tali soggetti tale da far ritenere che il terzo, con la propria attività, abbia inteso realizzare proprio quegli interessi al cui soddisfacimento i rapporti erano funzionali, non essendo sufficiente la mera corrispondenza del fatto illecito di quest'ultimo all'interesse dell'imprenditore. In assenza di riferibilità, anche indiretta, della condotta del terzo all'imprenditor e viene meno proprio il presupposto (il rapporto di concorrenza tra le parti) della fattispecie costitutiva degli atti di concorrenza sleale (Sez. 1, 22/09/2015, n. 18691”).

Il Tribunale non ritiene, per contro, sufficientemente provato il concorso nell'illecito da parte di alcuno degli altri soggetti evocati in giudizio.

Il tema deve essere trattato alla luce di una considerazione che risulta attagliarsi a ciascuno dei convenuti, ulteriori rispetto a CP_1 e a CP_5 , e che si trae dalla considerazione di quella stessa giurisprudenza, appena citata, che postula, perché l'extraneus concorra nell'illecito concorrenziale, che questi abbia compiuto l'atto lesivo. Le condotte ascritte non risultano invero integrare caratteri di illiceità intrinseca.

Quanto ad CP_10 la configurabilità di condotte idonee ad integrare la fattispecie dovrebbero collocarsi in epoca cronologicamente anteriore a quella della sua assunzione del ruolo di amministratore di CP_1 , atteso che da quel momento in avanti l'illecito è ascritto alla società, ed essa - come visto - ne risponde. Quanto al periodo precedente, ^{Part} sottolinea che egli aveva ricoperto non solo il ruolo di amministratore di ^{Part} fino al giugno 2012, ma che era stato consigliere delegato della controllante di ^{Part} fino a maggio 2013; sottolinea ulteriormente che CP_10 era socio di CP_1 , conosceva CP_5 ed era legato a CP_6 , essendo amministratore di una società, Org_25 (non si tratta di CP_2 convenuta nel presente giudizio) facente parte del Pt_9 [...]. Benché sia pacifica la partecipazione di CP_10 alla costituzione di CP_1 , insieme a CP_5 e alla CP_6 non è provato che in tale fase preparatoria egli sia stato messo al corrente dell'intendimento di CP_5 di traghettare fuori da ^{Part} tutte le essenziali componenti attive dell'azienda e tantomeno che abbia messo in atto condotte agevolative degli illeciti del CP_5 . L'attrice ha menzionato un ulteriore titolo di responsabilità dell' CP_10 laddove ha fatto riferimento all'art. 2395 c.c., al riguardo, tuttavia, il tribunale osserva che al di là della menzione della norma il titolo di responsabilità non è stato oggetto di alcuna specifica trattazione in fatto e in diritto. Peraltro, nelle conclusioni finali di parte attrice il ruolo di CP_10 - come anche della CP_6 e al pari degli altri convenuti CP_5 , CP_2 CP_3 CP_4 e CP_7 - viene esclusivamente qualificato in termini di realizzazione di atti di concorrenza sleale eseguiti in concorso e a sostegno dell'attività illecita di CP_1 .

Le medesime considerazioni si attagliano alle domande proposte nei confronti di CP_6 . Anche in questo caso, il titolo di responsabilità effettivamente fatto valere è solo quello dell'extraneus concorrente nell'illecito dell'imprenditore sleale. Al riguardo, come già rilevato a proposito di CP_10 non vi è prova che la CP_6 fosse stata resa edotta dal CP_5 di quanto egli aveva in animo di realizzare, o che la stessa CP_6 abbia realizzato alcuna condotta avente i connotati di illiceità. Anche l'ampia congerie di fatti, cui è stato dedicato anche un imponente sforzo istruttorio, correlati alla rappresentazione della CP_6 quale amministratore di fatto di CP_1 , tra il 2013 e il 2015 non risulta realmente conferente. Peraltro, la prova del ruolo di amministratore di fatto ascritto

alla CP_6 non appare essere stata offerta, non risultando fatti qualificabili in termini di ingerenza sistematica e pervasiva nella gestione sociale, come richieste dalla giurisprudenza costante (cfr. Cass. 21567/17; 28819/08; 9795/99). Ma anche ove la CP_6 fosse stata amministratore di fatto di CP_1 , la sua responsabilità personale dovrebbe individuarsi nel contesto dell'azione esercitata ex art. 2935 c.c. nei suoi confronti; tuttavia a tale riguardo valgono le considerazioni già espresse con riferimento alla posizione di CP_10 il tema non è realmente trattato dalla parte attrice, che insiste essenzialmente sul concorso della CP_6 nell'illecito concorrenziale, a riguardo del quale si è già detto come manchi la prova della messa in atto da parte della predetta convenuta di condotte che in sé considerate possano essere qualificate come illecite.

Ancor più evidente è l'infondatezza della domanda formulata nei confronti di CP_3 CP_4 e CP_2 . Le posizioni delle tre convenute possono esse valutate congiuntamente, perché del tutto sovrapponibili sono le condotte che H2H ascrive loro: si tratta di due pagamenti a fornitori di CP_1 eseguiti da CP_3 nel luglio 2013, di servizi amministrativi svolti a titolo oneroso da CP_2 per CP_1 nonché della concessione alla stessa di spazi ad uso ufficio, e del coinvolgimento di CP_4 in via occasionale in alcuni snodi amministrativi e organizzativi della prima fase di vita di CP_1 . In ciascun caso, si tratta di attività del tutto lecite, talune svolte a titolo oneroso e, inoltre, prestate a favore di una società, quale è CP_1 , inserita nel medesimo gruppo cui appartengono CP_3 CP_4 e CP_2 . Per le ragioni già più volte affermate, nessuna delle convenute ha dunque rivestito la qualità di extraneus nell'illecito concorrenziale di CP_1 .

Una specifica trattazione va destinata alla posizione di CP_7 , evocata anch'essa quale concorrente nell'illecito concorrenziale di CP_1 .

La convenuta ha in primo luogo sollevato una eccezione di carenza di giurisdizione. Premesso che, a mente del disposto dell'art. 7.2 Reg. 1215/2012, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, la convenuta ha eccepito che in nessun caso l'evento dannoso causato dalle condotte ascritte da ^{Part} CP_7 sarebbe avvenuto sul territorio italiano, perché detto evento coincide con il danno alla presenza sul mercato del concorrente leale, ed il mercato rilevante, quanto alle operazioni contrattuali asseritamente stornate con il concorso di CP_7 è quello francese e al più quello belga, ma non quello italiano; né deve indurre in confusione la considerazione del luogo ove si sia prodotto il danno patrimoniale che ^{Part} lamenta, non trattandosi dell'evento dannoso ma delle conseguenze dello stesso. Il Collegio osserva che la giurisdizione italiana deve essere riconosciuta, non certo perché assuma rilevanza il luogo in cui si

sarebbero prodotte le conseguenze patrimoniali dannose a carico dell'attrice, ma per l'identità di causa petendi e di petitum delle domande azionate nei confronti di CP_7 e di CP_1 , rilevante ex art. 8 reg. 1215/12, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata. L'impostazione delle domande di ^{Part} presenta CP_7 come autore o coautore con CP_1 delle medesime condotte illecite, e dunque come soggetto cui è da ascrivere integralmente l'esito di tali condotte, in concorso con gli altri convenuti: vale a dire il sostanziale storno di tutto il valore aziendale a vantaggio di CP_1 . Conseguenzialmente con tali premesse, H2H ascrive a CP_7 l'intero danno che afferma di aver sofferto.

Se dunque l'eccezione preliminare deve essere respinta, nel merito la domanda è del tutto priva di fondamento. H2H aveva organizzato per CP_7 l'operazione bijoux eclipsi, l'operazione coltelli Sabatier e l'operazione sticker e palline Spongebob, poi realizzate da CP_1 per la stessa CP_15 ovvero per CP_22 . Il concorso nell'illecito è ravvisato nel fatto che la società francese abbia proseguito le trattative a riguardo di tali operazioni con gli stessi soggetti che operavano per ^{Part} e che si sono, come noto, trasferiti in CP_1 ; la consapevolezza dello storno delle commesse (si tratterebbe di un autostorno, come esattamente osservato dalla difesa di CP_7 emergerebbe eminentemente dal fatto che i contatti via mail relativi all'operazione Org_22, inizialmente avvenuti tramite account aziendali di ^{Part} , si siano poi sviluppati anche con mail provenienti da indirizzi privati di CP_5 e Tes_5 e con risposte da parte di CP_7 su quei medesimi indirizzi. Quanto alle altre due operazioni, esse sono state poi realizzate da CP_22 , che è società distinta dalla odierna convenuta; il nesso tra CP_15 e l'avvenuta realizzazione dell'operazione sticker Spongebob da parte di [...] CP_22 è del tutto apodittico, ma lo è anche la collusione ascritta alla odierna convenuta a riguardo della tormentata vicenda dell'operazione coltelli Org_14 E' ampiamente narrato negli atti processuali di ^{Part} e di CP_7 che l'operazione promozionale coltelli Org_14 era stata realizzata da ^{Part} per CP_7 nel gennaio 2013; ^{Part} non era stata in grado di fornire tempestivamente i coltelli richiesti dalla clientela di CP_7 provocando una rottura di stock; a causa delle consegne ritardate, avvenute a luglio 2013, molti clienti che avevano prenotati i coltelli non li avevano più ritirati, così determinandosi un alto reso a carico di ^{Part} , con correlativo obbligo di quest'ultima di pagarne il prezzo; i coltelli erano stati ritirati da ^{Part} e dalla stessa rivenduti in perdita al titolare del marchio Org_14 dal quale li aveva immediatamente acquistati CP_1 per proporre ed effettuare un'operazione promozionale con quei

medesimi coltelli con CP_22 , con la quale Part aveva avuto contatti negoziali sin dai primi mesi del 2013.

Il Tribunale richiama anche in questo caso le considerazioni già ampiamente svolte sulla insussistenza di prova della messa in atto da parte della convenuta CP_7 di alcuna condotta illecita, sì che risulta del tutto da respingere la tesi del suo asserito concorso nella concorrenza sleale di CP_1 . E' stato persuasivamente osservato nell'ordinanza che ha confermato il rigetto del ricorso per sequestro conservativo nei confronti di CP_7 che *“tenuto conto della sua qualità di cliente, la circostanza di avere continuato a trattare con gli ex collaboratori di Part le medesime campagne promozionali, i cui risultati poi confluirono nella nuova società, non costituisce prova di un concorso da parte del cliente nella perpetrazione di atti illeciti. Per concorrere nell'illecito concorrenziale altrui, il terzo interposto deve avere una relazione qualificata in forza della quale egli agisce per conto e nell'interesse di quest'ultimo. La qualità di cliente, l'assenza di un rapporto di esclusiva con la ricorrente, il rapporto fiduciario instaurato con il medesimo personale, che prima lavorava per la ricorrente e continuava ad occuparsi delle medesime iniziative, ben lungi dal fare presumere una relazione d'interesse, depongono piuttosto per l'assenza di una relazione, tale da determinare un concorso del cliente nella perpetrazione di condotte illecite per avvantaggiare il concorrente sleale”*.

L'istruttoria espletata non ha aggiunto alcun ulteriore elemento di valutazione. La prosecuzione dei contatti con gli stessi interlocutori è coerente con la fisionomia di un rapporto contrattuale non in esclusiva tra cliente e fornitore di un servizio; non è emersa in alcun modo una relazione qualificata che riveli un agire di CP_7 nell'interesse di CP_1 .

Emerge, per contro, il carattere strumentale di una evocazione in giudizio non solo effettuata all'indomani della formazione di un titolo di condanna al pagamento del prezzo dei coltelli Org_14 che Part aveva l'indiscutibile obbligo di riacquistare, ma per di più intesa ad ascrivere a CP_7 non appena il danno asseritamente derivato dalla perdita delle tre operazioni contrattuali sopra ricordate, bensì addirittura dell'intero danno cagionato dalle condotte anticoncorrenziali di CP_1 per un importo affermato in oltre 17 milioni di euro; ciò che ha costretto CP_7 ad una difesa giudiziale di pari ampiezza (oltre a doversi difendere in un procedimento cautelare in corso di causa, rigettato nel doppio grado), senza che nel corso di una imponente istruttoria il quadro probatorio verso CP_7 sia stato in alcun modo arricchito. Per tali ragioni, oltre a respingere le domande proposte nei confronti di CP_7 il Tribunale ritiene sussistere i presupposti per la condanna di Part ex art. 96 III comma c.p.c..

Si viene ora ad esaminare la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice.

È stata svolta in giudizio una complessa consulenza tecnica d'ufficio. E' in primo luogo opportuno richiamare il quesito assegnato dal giudice istruttore, perché esso coglie esattamente la caratterizzazione della fattispecie, come emersa all'esito dell'esame del materiale probatorio.

Così recita il quesito:

“Dica il CTU letti gli atti e i documenti:

a) se, come allega l'attrice, il margine operativo lordo che la società ^{Part} ha conseguito nel secondo semestre del 2013 è stato effettivamente “negativo” nel senso di inferiore a quello che la società avrebbe conseguito se avesse eseguito quelle operazioni in tesi ideate e programmate nel 2013 da ^{Part} (Org_14 e Org_26) ma, poi realizzate da CP_1 , previa valutazione della sussistenza in H2H delle condizioni finanziarie necessarie alla realizzazione di dette operazioni;

b) quale sarebbe stato il margine operativo lordo che la società ^{Part} avrebbe conseguito se avesse replicato nel 2014 le operazioni (Org_27 Org_28 ^{Org_2} e Org_30 Organizzazione_31) realizzate nel 2014 da CP_1 previa verifica del fatto che ^{Part} disponesse della capacità finanziaria necessaria a realizzare quelle operazioni in quelle dimensioni e con detti clienti; in caso negativo accerti quale sarebbe stato ragionevolmente il margine operativo lordo che la società poteva conseguire continuando a promuovere le operazioni già sperimentate nella dimensione già realizzata;

c) quale sarebbe stato il margine operativo lordo che la società ^{Part} avrebbe conseguito se avesse realizzato nel 2014 le operazioni dalla stessa –in tesi- ideate ed impostate ma realizzate nel 2014 da CP_1 (“ Organizzazione_32 , “ Org_33 ”, “ Org_34 ”), previa verifica del fatto che ^{Part} disponesse della capacità finanziaria necessaria a realizzare quelle operazioni in quelle dimensioni e con quei clienti;

d) quale sarebbe stato il margine operativo lordo che la società ^{Part} avrebbe potuto conseguire nel 2015, alla luce dell'eventuale positivo esito delle verifiche di cui ai punti precedenti”.

Il quesito ricomprende la considerazione degli effetti della condotta illecita, vale a dire la sottrazione ad ^{Part} del business suo proprio costituito dalle commesse ideate ed in parte attuate, e chiede al consulente di ricostruire il MOL di tali commesse rispetto alle annualità sulle quali l'illecito ha avuto ripercussioni, con il correttivo della ragionevole esistenza in H2H, in quelle annualità, della struttura finanziaria sufficiente a realizzare quelle specifiche commesse. Trova in tal modo la sua esatta collocazione logica il controverso tema della capacità finanziaria di ^{Part} .

Come sopra accennato, l'argomento è stato utilizzato per cercare di confutare l'esistenza dell'illecito: H2H non avrebbe avuto la capacità finanziaria di sostenere le operazioni impegnative alle quali ambiva, e non avrebbe potuto affatto concludere contratti con operatori di mercato più rilevanti di quelli che sino a quel momento aveva avuto come clienti. Su tali temi sono stati sentiti molti testi (Pt_4 Tes_8 , Tes_9 Tes_1 CP_13 nonché le parti (Pt_5 quale a.u. di Part , CP_6 CP_10 CP_5). Il tema della capacità finanziaria di Part di sostenere nel futuro le operazioni che CP_1 ha stornato, come si è sopra chiarito, non interferisce né tantomeno elide il carattere illecito di una appropriazione dell'insieme degli elementi costitutivi dell'azienda, quali l'intera forza lavoro, la rete dei consulenti, l'insieme dei progetti contrattuali. L'esistenza di una struttura finanziaria adeguata all'effettiva esecuzione dei progetti incide invece sulla determinazione del danno risarcibile atteso che, ove l'acquisizione di una sufficiente capacità finanziaria non fosse ragionevolmente attribuibile ad Part per le annualità sulle quali il danno si proietta, la perdita delle commesse future non potrebbe ritenersi generativa di danno, perché nemmeno la stessa Part sarebbe stata in grado di realizzarle.

Le motivate conclusioni raggiunte dal CTU, che il Collegio fa proprie e viene ora ad illustrare, sono state formulate a seguito di prolungata ed approfondita indagine sviluppata nel pieno contraddittorio delle parti, nel corso della quale è stato esaminato un imponente materiale documentale (tra cui tutte le fatture emesse e tutte le fatture di acquisto di CP_1 , per oltre 5mila documenti; cfr. pag. 23-24 della relazione) e numerose memorie tecniche dei consulenti di parte. L'indagine effettuata non richiede alcuna ulteriore integrazione. Si rinvia alla relazione peritale (da pag. 26 a pag. 49) per la descrizione del metodo di individuazione del MOL e l'elaborazione dello stesso per ciascuna commessa.

Il CTU ha compiutamente indagato il profilo della capacità finanziaria di Part . Questi i dati che risultano determinanti. E' stato evidenziato, in primo luogo (pag. 57-58) che Part dall'inizio della sua attività e sino alla fine del 2012 aveva realizzato programmi di fidelizzazione senza rischio resi; nel 2013 la società ha fatto ingresso in un segmento di mercato più elevato con le operazioni [...] Pt_6 e coltelli Org_14 in cui il rischio resi è presente. E' proprio al rischio resi, come si è già ricordato, che si riconnette la necessità di adeguata struttura finanziaria a sostegno della singola operazione contrattuale. Se fin qui i dati fattuali sono pacifici, del tutto divergenti sono le valutazioni che i consulenti di parte di Part e di CP_1 , come anche il loro difensori, hanno proposto in ordine alla capacità finanziaria che avrebbe potuto caratterizzare H2H in correlazione all'ipotizzato svolgimento delle operazioni di fidelizzazione invece attuate dalla concorrente sleale. Al riguardo, il collegio condivide e fa proprie le motivate valutazioni espresse dal CTU, il quale (cfr. pag. 67-68) ha

considerato che le disponibilità finanziarie di ^{Part} potessero ritenersi ricomprese tra un minimo di 3/5 milioni e un massimo di 5/8,5 milioni, con la precisazione che la forbice tra i valori non dispiega alcuna rilevanza sulla individuazione del fabbisogno finanziario per ciascuna singola commessa di cui si discute in causa.

Tale individuazione della capacità finanziaria di ^{Part} è invero quella cui correttamente si deve addivenire sulla base degli elementi probatori acquisiti. Nemmeno l'attrice contesta che ^{Part} si trovasse sulle soglie di una fase imprenditoriale di espansione, che l'attrice medesima dipinge come assolutamente promettente e certamente realizzabile, tanto quanto i convenuti la descrivono come insostenibile proprio per la mancanza di dotazioni finanziarie adeguate e non destinata ad essere attuata. Osserva il Collegio che la considerazione compiuta dal CTU di una copertura finanziaria fino a 8,5 milioni risulta già comprensiva della considerazione di una garanzia di 5 milioni di euro che non risulta in realtà mai rilasciata (il documento che la proverebbe ha innescato esso stesso una delle innumerevoli diatribe tra le difese che hanno caratterizzato il giudizio: è vero che il doc.149 di parte attrice che dovrebbe offrirne prova è costituito da un documento del tutto inconferente rispetto al tema, e che esso è rimasto dunque privo di riscontri specifici, salvo il tentativo di produrre i doc. 217, 218 e 219 a preclusioni istruttorie ampiamente scadute). Il Collegio osserva dunque che il ragionamento svolto dal CTU, che ha ritenuto di includere quella garanzia di 5 milioni, ancorché non rilasciata ma ritenuta ragionevolmente ottenibile dalla società, esprime un'apertura alle prospettazioni di parte attrice nella misura massima consentita, oltre la quale sussistono invece solo congetture. Nulla suffraga infatti l'assunto attoreo della sicura disponibilità di ulteriori, e cospicui, mezzi finanziari, che la controllante, o meglio la famiglia cui fa capo il gruppo in cui ^{Part} è inserita, non avrebbero mancato di apportare; non è possibile ritenere che siffatto sostegno finanziario fosse destinato ad essere realmente ottenuto, e la situazione del business di ^{Part} quando ha subito l'illecito altrui era ancora troppo all'inizio dell'ipotizzato "salto " verso operazioni molto più impegnative e rischiose di quelle che aveva mai sostenuto in precedenza perché si possa trarre dall'osservazione della sua operatività una qualche reale conferma della sicura implementabilità del suo piano di crescita.

Il calcolo del margine complessivo lordo delle commesse nell'arco di tempo 2013-2015 realizzate da ^{CP_1} per effetto dell'illecito concorrenziale è indicato dal CTU in complessivi € 2.344.061, di cui € 2.976.689 nel 2013 e € 632.628 nel 2014; mentre è negativo per 943.997 nel 2015. E' qui da dire che il 2015 segna il crollo dell'avventura di ^{CP_1} , travolta da macroscopici errori gestionali di ^{CP_5} , tra i quali eminentemente una relevantissima sovrastima degli acquisti nell'operazione coltelli

Org_14 e nell'operazione *CP_21* con un conseguente impressionante volume di resi, o addirittura di prodotti mai ritirati presso il fornitore, rimasti a carico di *CP_1* .

Le divergenze registrate tra le parti con riferimento agli approdi della CTU sono state rese oggetto di osservazioni cui il CTU medesimo ha offerto compiute risposte, cui si rinvia (cfr. pag. 91-103). Si vogliono qui riprendere i profili di maggior rilievo. I dissensi si registrano con particolare riferimento alle valutazioni del CTU circa l'operazione *CP_21* e l'operazione coltelli *Org_14*

Quanto a *CP_21* il margine negativo per € 3.566.345 calcolato dal CTU non è stato incluso nel computo del margine operativo lordo che H2H avrebbe conseguito: la parte attrice reclama una ulteriore normalizzazione del margine di tale commessa per depurarlo dell'ammontare delle royalties che *CP_1* ha riconosciuto a *CP_21* pari a € 3.319.630 e ritenute, anche dal CTU, del tutto sproporzionate ed espressive di una gestione dissennata della commessa da parte di *CP_1* . Il CTU osserva però (pag. 92) che l'eliminazione della componente royalties avrebbe comunque lasciato negativo il margine della commessa e l'osservazione appare invero insuperabile.

Il secondo, rilevante tema di contrasto attiene all'operazione coltelli *Org_14* Il CTU ha stimato il fabbisogno finanziario per questa operazione (pag. 68-74, cui si rinvia) in circa 15 milioni di euro. Si tratta di un valore, per le ragioni già dette, che non può essere ritenuto ragionevolmente alla portata di H2H: ciò esclude insuperabilmente la necessità di apportare ulteriori elementi di normalizzazione alla ricostruzione del margine operativo sulla commessa.

In conformità agli esiti peritali, il Collegio conclusivamente quantifica in € 2.344.061,00 il danno cagionato ad H2H da *CP_1* in concorso con *CP_24* e condanna i predetti convenuti in solido al pagamento di tale somma in favore dell'attrice, oltre interessi legali sull'importo capitale rivalutatosi annualmente fino al soddisfo.

Le spese seguono il criterio della soccombenza.

CP_5 e *CP_1* vengono dunque condannati in solido alla rifusione delle spese legali sostenute da *Part* , che vengono liquidate avuto riguardo alla misura di accoglimento della domanda, con applicazione dei valori medi per la fase di studio e dei valori massimi per le ulteriori fasi, con applicazione dell'aumento del 30% in considerazione della soccombenza di due convenuti; e così in € 6.798.00 per esborsi e € 107.903,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge.

H2H è invece soccombente nei confronti dei restanti convenuti, con riferimento ad un valore di causa di circa 17 milioni di euro.

La liquidazione si effettua a valore intermedio tra i minimi e i medi in favore di CP_10 che non ha depositato nota spese, tenuto conto nella minore ampiezza dei temi controversi che lo coinvolgono, e dunque in € 80.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge.

La liquidazione si effettua invece a valori medi quanto a CP_6, e dunque in € 103.236,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge.

La liquidazione si effettua a valori medi nei confronti di CP_3 CP_4 e CP_2 e dunque in € 165.177,60 per compenso, considerato l'aumento per la pluralità di parti; oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge.

La liquidazione si effettua, infine, a valori medi in favore di CP_7 e dunque in € 103.236,00 per compenso quanto alla causa di merito, e in ulteriori € 10.000,00 per compenso quanto al doppio grado cautelare in corso di causa, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge. L'attrice è inoltre condannata alla rifusione delle spese documentate (cfr. doc. 13 allegato al foglio di p.c.) relative al compenso del ctp e pari a € 7.800.00. Si aggiunge la condanna ex art. 96 III comma c.p.c in misura pari alla metà delle spese come appena liquidate; dunque € 56.618,00.

Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico solidale di CP_5 e di CP_1
[...]

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) in parziale accoglimento delle domande di Parte_1 accerta la responsabilità ex art. 2598 n. 3 c.c. di Controparte_1 e di CP_5 in concorso con la predetta società e li condanna in solido al risarcimento dei danni cagionati all'attrice, liquidati in € 2.344.061,00 oltre interessi legali sull'importo capitale rivalutato annualmente fino al soddisfo;
- 2) rigetta ogni altra domanda;
- 3) condanna Controparte_1 e CP_5 in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società attrice, liquidate in € 6.798,00 per esborsi e in € 107.903,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge;

- 4) condanna *Parte_1* alla rifusione delle spese di lite sostenute da *Controparte_10*, liquidate in € 80.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge;
- 5) condanna *Parte_1* alla rifusione delle spese di lite sostenute da *CP_6*, liquidate in € 103.236,00 per compenso oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge;
- 6) condanna *Parte_1* alla rifusione delle spese di lite sostenute da *CP_3*, *CP_4*, *CP_2* in solido, liquidate in € 165.177,60 per compenso oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge;
- 7) condanna *Parte_1* alla rifusione delle spese di lite sostenute da *CP_7* liquidate in € in € 103.236,00 per compenso e in ulteriori € 10.000,00 per compenso quanto al doppio grado cautelare in corso di causa; oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge; nonché alla rifusione delle spese documentate relative al compenso del ctp e pari a € 7.800.00; oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge; condanna inoltre l'attrice al pagamento in favore di *CP_7* dell'importo di € 56.618,00 ex art. 96 III comma c.p.c.,
- 8) pone definitivamente a carico di *Controparte_1* e di *CP_5* tutte le spese di CTU.

Così deciso in Milano, il 25 febbraio 2021.

Il Giudice est.
dott. Caterina Macchi

Il Presidente
dott. Claudio Marangoni